

1516864-68.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516864-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516864-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RODRIGUES FERREIRA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 6 de outubro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Pedro André Picado Alonso, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o acusado; LUCAS RODRIGUES FERREIRA. Iniciados os trabalhos, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas, GCM, Edson Barreto de Sousa e Fernando Leandro Lopes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução,

estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, LUCAS RODRIGUES FERREIRA foi denunciada e se vê processada pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 16h48min, na Estrada Nossa Senhora da Fonte, n. 347, Guaianases, nesta cidade e comarca, juntamente com o adolescente Jefferson Cordeiro Ferreira, conluiados, trazia consigo, 101 invólucros plásticos e 185 micro tubos plásticos, contendo substância substância entorpecente denominada Cocaína, com peso de 38,7g; 43 porções de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida vulgarmente como maconha, com peso líquido de 79,9g; e 67 invólucros plásticos contendo substância entorpecente "Crack", com peso líquido de 15,9g; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 18/21. O réu foi devidamente notificado e citado e apresentou resposta à acusação (fls. 145/147 e 167). Designada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogada. É o breve resumo do necessário. O pedido formulado na ação penal é procedente, porquanto, finda a persecução penal, os elementos de prova combinados permitem que se afirme que a hipótese acusatória exposta na denúncia restou demonstrada para além da dúvida razoável. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência a fls. 26/33, auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação de fls. 18/21 e exame químico-toxicológico de fls. 151/153. A autoria, de igual sorte, é incontroversa. O guarda municipal Fernando Leandro Lopes reconheceu o acusado. Disse que estava com uma missão de patrulhar uma área de APP, que tem um córrego que desagua num piscinão. No trajeto, viram quatro indivíduos sentados. Quando se aproximaram, um dos rapazes gritou sujou. Viu o acusado com a sacola na mão e correu. Acabou torcendo o pé no momento de correr, então pegou a sacola, com cocaína, maconha e "crack", embaladas individualmente para consumo. Seu parceiro correu atrás do acusado e o prendeu. Dentro da sacola tinha contabilidade do tráfico. O acusado disse que é usuário e que estava no local apenas para usar. Não foi encontrado dinheiro. Viu o acusado correndo com a sacola e dispensando ela. Também foi apreendido um adolescente que estava no local e disse que estava ali para usar drogas com o acusado. O guarda municipal Edson Barreto de Sousa reconheceu o acusado e disse que estava em patrulhamento quando viu o acusado com mais três indivíduos na rua. Quando se aproximou, os três fugiram. O acusado também tentou deixar o local. Viu o acusado correndo e dispensando a sacola com as drogas. Abordou o acusado e seu parceiro de farda pegou a sacola com as drogas. Na sacola havia várias drogas, embaladas individualmente. O local é ponto conhecido como de venda de drogas. A localidade é comumente patrulhada pela guarda, pois o local é área de preservação permanente. O acusado disse que estava no local para consumir drogas, o mesmo que disse o adolescente. Os depoimentos dos guardas foram uniformes, sem quaisquer contradições. Não há dúvidas que o acusado estava no local para fazer a venda das drogas. A quantidade e diversidade de drogas, associadas às anotações apreendidas em seu interior, conforme laudo juntado as fls. 186/187, é incompatível com qualquer argumento de que as drogas estavam com o acusado para consumo pessoal. Da mesma forma, o acusado não tem como sustentar que as drogas não eram suas, pois ambos os guardas relataram que a sacola estava em seu poder. Na fase policial, o acusado ficou em silêncio. Em juízo, LUCAS negou a prática do delito. Disse que faz uso de cocaína e que foi ao local para comprar drogas. Foi quando os policiais chegaram, os rapazes correram e os policiais o prenderam. Disse que correu porque ficou assustado. Falou que estava trabalhando. Disse que conhece o adolescente e que faz uso de drogas com ele. Diante de tudo o que foi exposto, resta claro que o réu estava na prática do tráfico ilícito de entorpecentes e foi surpreendida pelos guardas. A apreensão e o relato dos guardas apontam no mesmo caminho, não havendo dúvidas sobre a prática delitiva. A versão do acusado é desmentida, pois não faria sentido que um usuário ficasse responsável por trazer as drogas vendidas. Certa a responsabilidade penal, necessária a imposição de pena. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada bem acima mínimo legal, haja vista a variedade e a enorme quantidade de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei de

Drogas, já que o acusado trazia cocaína pura, "crack" e maconha. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incabível a aplicação da causa de diminuição especial de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a prova demonstrou que o acusado se dedica a atividades criminosas. O réu trazia mais de 350 porções de drogas, sendo 101 invólucros plásticos e 185 micro tubos plásticos contendo cocaína, 43 porções de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida vulgarmente como maconha, e 67 invólucros plásticos contendo substância entorpecente "Crack", o que evidencia que já estava bem inserido na criminalidade. Não restou demonstrada a causa de aumento do art. 40, VI, na medida em que faltam provas de que o adolescente estava envolvido no tráfico de drogas. O regime de pena deve ser o fechado. O tráfico de drogas é crime equiparado à hediondo, que necessita de tratamento diferenciado, conforme determinado pela própria Constituição da República, sendo de extrema gravidade e causador de outros crimes. Sua prática propicia o consumo, estimula o vício e atemoriza a população. Com isso, necessário o combate efetivo a este crime que abala a saúde pública do país e a segurança da população. Não é possível substituição ou suspensão da pena. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer seja acolhido o pedido formulado na denúncia, para condenar LUCAS RODRIGUES FERREIRA pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, LUCAS RODRIGUES FERREIRA está sendo processado por suposto tráfico de drogas - artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Regularmente processada, foram ouvidos somente os guardas civis envolvidos na ocorrência, com derradeiro interrogatório do acusado. Os Guardas Civis aduziram que viram o réu estava junto com outras três pessoas, em movimentação aparente de tráfico de drogas. Quando os indivíduos viram a chegada dos guardas, tentaram se evadir. Foram em direção ao réu, que estava com a sacola, que foi dispensada por ele. Conseguiu recuperar a mochila, abrodar o réu e um adolescente. O réu, em interrogatório, negou a prática dos fatos, aduzindo ser usuário. Pois bem, Excelência. PRELIMINARMENTE, observa-se que as provas devem ser declaradas ilícitas. Com efeito, restou evidente a violação ao disposto no art. 158-B do CPP no sentido de que é necessário o rastreamento do vestígio em etapas que não foram observadas. Ora, o inciso II informa que o local deveria ter sido isolado, ou seja, quando os policiais supostamente encontraram as drogas na posse do indiciado, deveriam ter isolado o local; além disso, o art. 158-C, em seu §2º, informa a proibição de entrada nos locais isolados antes da liberação por perito. Aqui, o local não foi isolado e não houve comparecimento de qualquer perito, conforme se extrai do boletim de ocorrência e dos depoimentos. Na sequência, seria necessária a descrição detalhada do vestígio, exatamente da maneira como encontrado, e seria indispensável a descrição no laudo oficial, ou seja, o perito oficial deveria ter comparecido ao local dos fatos ou, no mínimo, os policiais deveriam ter fotografado a cena (inciso III). As demais exigências legais - fase de coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte - incisos IV a X -consequentemente, restaram comprometidas já que o que aconteceu, pelo que se extrai dos autos, foi o transporte da droga na própria viatura, sem a observância dos ditames legais. Pode ter havido, no meio do caminho, algum erro, troca ou desvio, não existindo segurança nesta questão. Observa-se que a prova da materialidade, aqui, está longe de ser inquestionável porque, inclusive, não existe a documentação exigida pelo inciso VII do art. 158-B do CPP: não há código de rastreamento, não há protocolo de recebimento da droga e, menos ainda, a devida identificação de quem a recebeu. Assim, não havendo prova da materialidade do delito, de rigor a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, II, do Código Penal. Ainda em sede preliminar, é forçoso reconhecer que a atuação dos GCMs no presente caso revestiu-se de inconstitucionalidade. Com efeito, o STF, na ADI n.º 2827-RS, entendeu o rol disposto no caput artigo 144 da Constituição da República é taxativo. In verbis: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional nº 19, de 16 de julho de 1997, à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; expressão "do Instituto-Geral de Perícias" contida na Emenda Constitucional nº 18/1997, à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; e Lei Complementar nº 10.687/1996, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar

nº 10.998/1997, ambas do Estado do Rio Grande do Sul 3. Criação do Instituto-Geral de Perícias e inserção do órgão no rol daqueles encarregados da segurança pública. 4. O requerente indicou os dispositivos sobre os quais versa a ação, bem como os fundamentos jurídicos do pedido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 5. Observância obrigatória, pelos Estados-membros, do disposto no art. 144 da Constituição da República. Precedentes. 6. Taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública, contidos no art. 144 da Constituição da República. Precedentes. 7. Impossibilidade da criação, pelos Estados-membros, de órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da Constituição. Precedentes. 8. Ao Instituto-Geral de Perícias, instituído pela norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à segurança pública. 9. Violação do artigo 144 c/c o art. 25 da Constituição da República. 10. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente. Dessa maneira, se o rol do artigo 144 da CR é taxativo, não se pode admitir que a Guarda Municipal atue em exercício de atividade de polícia ostensiva, que é própria da polícia militar, até porque a seus agentes cabe tão-somente a proteção do patrimônio municipal, nos termos do parágrafo 8º do mesmo dispositivo constitucional. De outra parte, a prova material é ilícita, eis que houve apreensão de drogas por guardas civis metropolitanos. Com efeito, consta da denúncia que guardas civis metropolitanos teriam vista dois indivíduos e suspeitaram de venda de entorpecentes, razão pela qual perseguiram o réu e realizaram abordagem. Ocorre, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça no Resp 1977119 - SP, tal abordagem realizada por guardas civis metropolitanos é ilícita, eis que não tem relação com a proteção de patrimônio municipal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL Nº 1977119 - SP (2021/0391446-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ RECORRENTE: DOUGLAS DOS SANTOS ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO BRUNO SHIMIZU - DEFENSOR PÚBLICO - SP281123 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO EMENTA RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.1.A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art.144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.2.Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais - apesar da sua relevância - não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.3.Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.4.A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para "Polícia

Municipal". Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.⁵A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 6.Ao dispor no art. 301 do CPP que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipotente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.⁷Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de "qualquer do povo"; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.⁸É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9.Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência

com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.¹⁰Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois

de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.¹¹ Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.¹² Recurso especial provido. Consta da. R. decisão: "A rigor, nem mesmo a possibilidade, em si, de guardas municipais realizarem busca pessoal - ainda que presente justa causa para a medida - me parece sedimentada na Corte. Chamo a atenção, neste ponto, para o voto-vista do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro no HC n. 561.329/SP, acima citado, ocasião em que acompanhou as conclusões do relator e destacou entender "descabida a atuação da guarda municipal em razão de suas atribuições não abarcarem o policiamento ostensivo e a realização de busca pessoal, atuação que causa gravame às liberdades individuais e, por isso, autorizada constitucionalmente tão somente a restritos órgãos e agentes estatais, como as polícias administrativas e seus agentes no exercício de suas funções, ou sob autorização judicial" (grifei). (...) A finalidade legal da medida, dessa forma, é probatória, razão pela qual, mesmo se presente a fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só pode ser realizada pelos agentes pertencentes aos órgãos estatais com atribuição para a segurança pública e a prática de diligências probatórias criminais invasivas, o que não é o caso, em regra, das guardas municipais. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. Com base nessa mesma premissa, a Quinta Turma deste Superior Tribunal já declarou ilícita a revista pessoal feita por agente de segurança privada da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ocasião em que assinalou que "somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes, estão autorizados a realizarem a busca domiciliar ou pessoal". A apreensão de drogas foi realizada após abordagem ilícita, eis que eventual comércio de drogas somente poderia ser constatado após abordagem (as testemunhas confirmaram que somente após a abordagem é que puderam constatar que efetivamente se tratava de tráfico de drogas), não sendo o guarda civil metropolitano integrante da polícia e não havendo relação da intervenção dos agentes públicos com a proteção do patrimônio municipal. Observe-se, portanto, que não foi lícita a intervenção realizada pelos guardas civis metropolitanos, razão pela qual é ilícita a prova da materialidade. Assim, de rigor a absolvição do réu por ausência de materialidade. Assim, ante e ilicitude da abordagem e, consequentemente, da prova da materialidade, requer-se a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. No mérito, não há provas suficientes para a condenação, não tendo sido a versão do réu sido confirmada pelas provas produzidas. Há apenas e tão somente o relato de dois guardas civis metropolitanos, que, por óbvio, tentaram legitimar a prisão por eles efetuada. A solução do direito, neste caso, só pode ser a absolvição! Nesse sentido o entendimento de nossos Tribunais e doutrina: "Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da Instrução, paira 'dúvida razoável' sobre sua existência, 'não pode ter tido como provado, deve ser considerado inexistente, não provado'." (Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no Processo Penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45) "TÓXICO - Crime de tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga

apreendida Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido." (Ap. 990.08.094.477-0 - 16a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Newton Neves - julgado em 22.09.09). O direito penal, como é sabido, não admite tamanha fragilidade probatória, muito menos provas obtidas de modo obscuro, repleto de lacunas e inconsistências, de maneira que prevalece a dúvida, o que impõe o decreto absolutório como medida de justiça. Nesse sentido: "Absolvição pelo princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136). Conclui-se, portanto, que o réu deve ser ABSOLVIDO com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, por apego aos princípios da oportunidade e da mais ampla defesa, requer-se: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a prevalência de circunstâncias favoráveis, bem como o afastamento da agravante relativa ao estado de calamidade, eis que na data em que o réu teria praticado os fatos narrados na denúncia a situação fática do município de São Paulo já não se apresentava como calamitosa, com normal circulação de pessoas; b) é caso, ainda, de redução máxima da pena, diante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ressalta-se que o §4º do art.33 da lei de Drogas foi criado com o intuito de revestir de proporcionalidade/razoabilidade a pena àqueles acusados de tráfico que notadamente não pertencem a organizações criminosas. Assim, desconsiderá-lo exclusivamente por antecedentes criminais seria um retrocesso ao permitir o retorno do direito penal do autor, visto que, no caso, o indivíduo será penalizado, não pelo crime pelo qual está sendo processado, mas por outra conduta pela qual já foi condenado e, muitas vezes, já cumpriu sua pena. Senão, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, c) requer-se ao menos que o aumento pela reincidência seja afastado na segunda fase para impedir o bis in idem na terceira fase. Ademais, na segunda fase, de rigor afastamento da agravante relativa ao cometimento de delito durante período de calamidade, eis que não há relação de causa e efeito entre o estado de pandemia e o cometimento do tráfico de drogas. Quanto ao regime, d) requer-se a concessão de regime mais brando, diverso do fechado, e) com recurso em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LUCAS RODRIGUES FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, o dia 26 de julho de 2022, por volta das 16h48min, na Estrada Nossa Senhora da Fonte, n. 347, Guaianases, nesta cidade e comarca, o acusado de nome LUCAS RODRIGUES FERREIRA, qualificado à fl. 13, juntamente com o adolescente Jefferson Cordeiro Ferreira, conluiados, trazia consigo, 101 (cento e um) invólucros plásticos e 185 (cento e oitenta e cinco) micro tubos plásticos, contendo substância substância entorpecente denominada Cocaína, com peso de 38,7g (trinta e oito gramas e sete decigramas); 43 (quarenta e três) porções de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida vulgarmente como maconha, com peso líquido de 79,9g (setenta e nove gramas e nove decigramas); e 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo substância entorpecente "Crack", com peso líquido de 15,9g (quinze decigramas); tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de fls. 18/21, oportunidade

em que foi preso por guardas civis metropolitanos que faziam patrulhamento em zona de preservação ambiental municipal e se depararam com o acusado e outras pessoas que correram. O acusado foi visualizado na posse de uma sacola, no interior da qual foram encontrados os entorpecentes embalados e prontos para a venda no varejo. O acusado fez uso do direito de permanecer calado na fase policial, enquanto o adolescente, em resumo, disse que foi no local para comprar drogas e encontrou com

o réu no momento do uso, mas não sabia se ele traficava drogas no local. A liberdade provisória foi deferida. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A defesa preliminar não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia que ocorreu no dia 19 de setembro de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos. Ao final, em sede de debates, a acusação, em resumo, pediu a condenação, enquanto a defesa, em resumo, pediu a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das drogas foi preservada, considerando as peculiaridades do caso e a própria natureza do crime imputado. O fundado motivo para a legitimação da busca e apreensão pessoal ficou demonstrado no fato de que o réu estava com uma sacola na mão, tentou disfarçar diante da presença policial, em um ponto conhecido como de venda de drogas, além do que fugiu. Com relação à regularidade da prisão por parte de Guardas Civis Metropolitanos, necessário consignar que nos termos do artigo 301 e s.s. do Código de Processo Penal qualquer um do povo pode prender uma pessoa em flagrante delito, o que ocorreu no presente caso, haja vista tratar-se a posse de drogas para o tráfico ilícito de entorpecentes crime permanente que permite a prisão em flagrante delito. Além disso, as Guardas Civis representam forças auxiliares das polícias estaduais e federais, sendo que em muitos municípios fazem a diferença entre a paz pública e o caos, haja vista o número elevado de moradores para o número de policiais disponíveis. Conforme já foi decidido anteriormente, não se discute o fato de que a Guarda Municipal não possui poder de polícia conforme atribuições definidas na Constituição Federal, ou seja, não pode cumprir mandados de busca e de apreensão, bem como investigar denúncias anônimas. Porém, isso não significa que os guardas municipais, enquanto agentes públicos com o dever de zelar pelos próprios da municipalidade, bem como na situação de qualquer um do povo, diante de uma situação de flagrante delito, como no presente caso, podem e devem intervir para manter a ordem pública, sob pena de prevaricação em face da sua função de agente público. II. O acusado não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. III. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o réu não confessou o crime na fase policial e a quantidade de drogas é expressiva para o tráfico no varejo. IV. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETILECGONINA), na sua forma em pó e pedra, e "Maconha" (cannabis sativa L), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, conforme laudos periciais provisório e definitivo. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram "Cocaína" e "Maconha" (fls. 151/153), a materialidade do crime está provada. VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial,

os depoimentos dos guardas civis responsáveis pela prisão, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, sem me olvidar das declarações do acusado e as manifestações finais das partes, a condenação é de rigor e pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes apenas. Conforme restou apurado, em síntese, o dia 26 de julho de 2022, por volta das 16h48min, na Estrada Nossa Senhora da Fonte, n. 347, Guaianases, nesta cidade e comarca, o acusado de nome LUCAS RODRIGUES FERREIRA, qualificado à fl. 13, trazia consigo, 101 (cento e um) invólucros plásticos e 185 (cento e oitenta e cinco) micro tubos plásticos, contendo substância substancia entorpecente denominada Cocaína, com peso de 38,7g (trinta e oito gramas e sete decigramas); 43 (quarenta e três) porções de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida vulgarmente como maconha, com peso líquido de 79,9g (setenta e nove gramas e nove decigramas); e 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo substância entorpecente "Crack", com peso líquido de 15,9g (quinze decigramas); tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de fls. 18/21, oportunidade em que foi preso por guardas civis metropolitanos que faziam patrulhamento em zona de preservação ambiental municipal e se depararam com o acusado e outras pessoas que correram. O acusado foi visualizado na posse de uma sacola, no interior da qual foram encontrados os entorpecentes embalados e prontos para a venda no varejo. O acusado fez uso do direito de permanecer calado na fase policial, enquanto o adolescente, em resumo, disse que foi no local para comprar drogas e encontrou com o réu no momento do uso, mas não sabia se ele traficava drogas no local. O acusado, ao ser interrogado, declarou que foi para o local comprar drogas e pediu para fazer uso delas, momento em que foi preso pelos guardas civis metropolitanos, enquanto os traficantes fugiram. Já os Guardas Civis Metropolitanos, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, de forma uníssona e segura, informaram que estavam realizando patrulhamento municipal em local de proteção ambiental de interesse e proteção municipal, quando verificaram o réu e outras pessoas juntas em um local conhecido como de venda de drogas. Diante da presença dos guardas civis, o acusado, o qual estava com a sacola das drogas na mão, bem como outros rapazes correram, acabando por ser preso e encontradas as drogas dentro da sacola. Importante mencionar que o acusado fez uso do direito de ficar calado na fase policial, algo incomum para alguém preso e acusado injustamente. Também, as imagens da audiência de custódia não demonstram que ele estava usando drogas e bebendo a noite inteira como alegado. Inclusive, adolescente apreendido com o acusado foi ouvido pela autoridade policial e fez consignar a sua versão, ou seja, caso os direitos do réu não fossem respeitados o adolescente também não teria sido envolvido. Portanto, a autoria e a materialidade do crime, bem como do dolo do tráfico ilícito de drogas são inquestionáveis. O crime em questão se consumou quando cessou o crime permanente com a prisão do réu. Todavia, com relação ao adolescente Jefferson Cordeiro Ferreira, não restou demonstrado que ela agia conluído ou que tivesse comprado drogas do acusado, até porque não foram encontradas drogas com ele e os guardas civis não viram o réu vendendo drogas para o adolescente. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. VII. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, as quais não são diversas de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há alterações nas penas iniciais pela ausência de circunstâncias legais modificadoras. Já na terceira fase da aplicação da pena, por conta do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, uma vez que o réu é primário e não há provas de que faça parte de organização criminosa, as penas são reduzidas em 2/3, passando para 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. Considerando as peculiaridades do caso, a posição

jurisprudencial majoritária dos E. Tribunais Superiores, o réu poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial ser o aberto. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para, após absolver o réu do disposto no artigo 40 VI, da Lei Federal nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenar LUCAS RODRIGUES FERREIRA, RG/SP nº 50965251, CPF nº 452.608.498-09, nascido em 12/08/1995, filho de Luiz Carlos da Silva Ferreira e de Diva Rodrigues da Silva, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 166 dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º da Lei Federal nº 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, uma vez que o acusado possui patrono constituído e declarou ter emprego fixo. Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para novos exames, uma vez que já há laudo definitivo e ele não foi impugnado. Conforme posição majoritária dos E. Tribunais Superiores, aplica-se ao caso o disposto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo mesmo prazo e em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais. Também, por 10 dias multa, no valor mínimo unitário legal, a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Os valores eventualmente apreendidos e outros bens estão relacionados com o tráfico de drogas, uma vez que apreendidos junto com as drogas e em local de traficância conhecida, motivos pelos quais determino a perda e o encaminhamento para o fundo nacional criado com essa finalidade (o dinheiro), bem como a destruição do restante. Determino a perda e a destruição dos demais bens apreendidos e não devolvidos, em face da relação com o crime praticado. Oficie-se para tanto. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital